

1503260-02.2020.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Raineri Simão

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado. Vejamos. A materialidade está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, auto de apreensão de fls. 06, laudo de exame químico toxicológico de fls. 11/13. A autoria, de igual modo, restou seguramente demonstrada, muito embora o acusado negue a prática do tráfico de drogas. Alegou na fase extrajudicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Fórum, Vila Nossa Senhora do Carmo - CEP 14801-425, Fone: (16)

3336-1888, Araraquara-SP - E-mail: araraq3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503260-02.2020.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2256696/2020 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 9510843 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA,
2082/20/908 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA, 2256696 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO MARCELINO SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - (A.P. nº 1144/2020 - artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 cc artigo 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal) - Em 28 de junho de 2022, às 15h30, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, DR. ROBERTO RAINERI SIMÃO, que se achava presente comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado, para audiência virtual de instrução e julgamento, nos autos da Ação Penal supramencionada, constatou-se a presença do representante do Ministério Público, DR. MARCEL ZANIN BOMBARDI. Presente o réu LUIZ FERNANDO MARCELINO SILVA. Presente para defendê-lo, o Defensor Público, DR. JOÃO FINKLER FILHO. Todos acima referidos já estão devidamente qualificados nos autos, dispensando-se assim a providência constante do artigo 147, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Antes do início da audiência, o MM. Juiz explicou que, seguindo a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e orientação da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, no Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Teams/Microsoft, bem como nos termos

do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça; do § 5º do artigo 367 do Código de Processo Civil; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal; e artigo 150 e seguintes, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça e demais corolários legais à espécie. Abertos os trabalhos, as partes manifestaram-se expressamente pela concordância da realização da audiência conforme as normas acima referidas, apontando o Ministério Público e Defesa as ressalvas para incomunicabilidade das pessoas a serem ouvidas, porquanto, pelo MM. Juiz foi dito: "Os depoimentos serão tomados cada um de per si, de modo que uns não saibam nem ouçam o que foi dito pelos outros, em cumprimento ao que determina o artigo 210, do Código de Processo Penal." Após a identificação pessoal, através da exibição de documento original com foto, visualizado no início de cada depoimento, foi o réu Luiz Fernando Marcelino Silva interrogado, sendo-lhe previamente assegurado o direito de entrevista reservada com seu Defensor, bem como informado o que determina o artigo 186 do Código de Processo Penal, acerca do direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Em sequência, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo outras provas a serem produzidas, considerava encerrada a instrução processual e determinava o oferecimento das alegações finais orais. Durante os debates, pelo Ministério Público foi dito: "LUIZ FERNANDO MARCELINO SILVA está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas condições de tempo e local descritos na denúncia e, portanto, durante estado de calamidade pública, foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo e transportando, para fins de tráfico, 13 (treze) comprimidos de METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA), com peso de 3,55g., sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. É dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram o denunciado, em via pública, com uma bicicleta, em atitude suspeita, pois ao perceber a presença da viatura demonstrou nervosismo e saiu pedalando rapidamente, o que motivou a abordagem. Assim, em busca pessoal, os agentes públicos encontraram, na bicicleta que ele conduzia, os 13 (treze) comprimidos de Ecstasy, que estavam dentro de um saco plástico pequeno, devidamente embalados e prontos para o comércio, eis que ele trazia consigo para fins de tráfico. A propósito, ao ser questionado pelos militares sobre a droga, o denunciado confessou a propriedade dos comprimidos e disse tê-los comprado de um desconhecido, sendo que iria vendê-los em uma festa ('baile Funk') que ocorreria naquela data, nas proximidades de Furnas, na área rural desta cidade. A denúncia foi recebida em 24/03/2021 (fls. 43/44). O réu, devidamente citado - fls. 61, apresentou defesa escrita a fls. 65/66, o que não evitou a confirmação do recebimento da denúncia, conforme decisão de fls. 67. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e nenhuma de defesa, procedendo-se, ao final, o interrogatório do acusado. É, em síntese, o relatório. A presente ação penal deverá ser julgada procedente. Com efeito, o contexto probatório produzido nos autos se mostra apto para embasar o decreto condenatório. Restou incontroversa a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado. Vejamos. A materialidade está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, auto de apreensão de fls. 06, laudo de exame químico toxicológico de fls. 11/13. A autoria, de igual modo, restou seguramente demonstrada, muito embora o acusado negue a prática do tráfico de drogas. Alegou na fase extrajudicial (fls. 29) que adquiriu a droga para consumi-la com os 'moleques' em um baile 'funk'. Em juízo, confirma que estava de posse do entorpecente, pois se locomovia da casa de sua namorada para a sua. Disse que a noite riria em um baile 'funk' onde consumiria a droga com a namorada e a amiga dela. Contudo, não soube explicar os efeitos da aludida droga, dizendo apenas que duraria cerca de 01 hora. Evidente que suas alegações visam apenas a tentativa de justificar a quantidade de entorpecente encontrada em seu poder. Mencionou, inclusive, sem qualquer fundamento que pagou a importância de R\$ 10,00 por comprimido, destoando do que se vê nos demais processos deste tipo. Evidente, portanto, que sua negativa não procede. A propósito, quando da sua prisão, confirmou para os policiais que iria vender o entorpecente no aludido baile. Nítido que o réu não tem capacidade financeira

suficiente para dar aos seus amigos entorpecentes para serem consumidos em um baile 'funk'. Não bastasse isso, essa conduta também configuraria o crime em apreço. Nota-se que o valor de cada comprimido de ecstasy no meio criminoso é alto e faz desse tipo de atividade um diferencial, pois, o público alvo é, de regra, os frequentadores de festas. Os policiais militares confirmaram que surpreenderam o réu andando de bicicleta com a droga em uma sacolinha, sendo que ao ver a viatura, apresentou nervosismo e tentou evitar a abordagem. Porém, foi abordado e em seu poder a droga foi encontrada, momento em que confessou que venderia esse entorpecente em uma festa que aconteceria na zona rural de Araraquara, chamado de 'pancadão de furnas'. Mencionou que o valor de cada comprimido deste é vendido em torno de R\$ 40,00/R\$ 50,00 para um público seletivo e que os efeitos dessa droga chegam a durar cerca de 12 horas. Deixou claro que o réu não estava traficando no local da abordagem, mas sim trazendo a droga consigo para vendê-la na festa 'funk' que aconteceria à noite. Assim a quantidade e a natureza de droga encontrada em seu poder, nas circunstâncias em que foi, bem como pela confissão informal feita, não deixam dúvida do cometimento do crime pelo réu. Imperiosa, pois, a procedência da presente ação penal. A pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal, diante da quantidade e natureza da droga apreendida, nos moldes do artigo 42 da Lei 11.343/06. O acusado, embora primário - fls. 54/58, já vinha se dedicando a essa atividade criminosa pois, repita-se, que esse público alvo é muito específico. Inviável, pois, a concessão de qualquer benefício legal. O regime a ser fixado deverá ser o fechado, único adequado à hipótese, diante da gravidade e hediondez do crime cometido. Por fim, fica reiterado nesse momento o perdimento dos bens apreendidos para a União, nos termos do disposto no artigo 63 e ss. da Lei 11.343/06. Nestas condições, diante do exposto, aguarda-se a procedência da presente ação penal, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia." Por outro lado, pela Defesa foi dito: "MM. Juiz, inicialmente me reporto ao relatório fático elaborado pelo Ministério Público. Após atenta análise dos presentes autos, impõe-se a desclassificação dos fatos para a contravenção prevista pelo Art. 28 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, não há nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa capaz de comprovar a alegada traficância. Assim sendo, revela-se frágil o conjunto probatório produzido pelo Ministério Público em desfavor do acusado, eis que os depoimentos colhidos em sede judicial não fornecem a necessária certeza para a condenação. Simplesmente não há como se ter plena convicção da culpabilidade do réu. No mais, evidentemente não se pode afirmar que a palavra dos policiais não merece valorização pelo Poder Judiciário, mas é evidente que não pode, isoladamente, sustentar condenação criminal. Ainda, imperioso observar que a acusação não produziu qualquer outra prova que indique a alegada relação do acusado com os fatos sob apuração. Não existe nenhuma gravação da ação delituosa, ou qualquer tipo de perícia ou indicando a participação do autor na empreitada criminosa. Veja-se, ademais, que o próprio acusado, em interrogatório sólido e convincente, negou a prática do delito, afirmando que a pouca droga apreendida consigo se destinava a consumo próprio. A quantidade extremamente pequena de droga apreendida seguramente reforça a alegação de mera posse de drogas para uso pessoal. Nesse ponto, de se ressaltar que sua própria ex-namorada salientou isso, sendo que ela apenas não foi ouvida em juízo porque faleceu em acidente automobilístico. Assim, em arremate, sobejamente demonstrada a ausência de prova robusta capaz de ensejar a condenação do acusado nos termos da denúncia, inevitável a desclassificação dos fatos para o Art. 28 da Lei nº 11.343/06. Em caso de condenação, porém, pugna-se pela fixação da pena-base em seu mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa. A agravante relativa ao cometimento de delito em situação de calamidade pública deve ser afastada, visto que não há demonstração de nexo de causalidade entre a calamidade mencionada pela denúncia e o fato criminoso nela descrito. Ademais, os decretos federais, estaduais e municipais editados acerca do tema têm por único objetivo afastar as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lcp nº 101/00) no curso do período de pandemia. Caso reconhecida, porém, deve prevalecer a atenuante, pois preponderante, na forma do Art. 67 do Código Penal. Ainda, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado

em seu patamar máximo, eis que preenchidos todos os requisitos legais para tanto e é pouca a quantidade de droga apreendida. Aliás, o argumento ministerial de que o acusado "já vinha se dedicando a essa atividade criminoso pois, repita-se, que esse público-alvo é muito específico" é risível e demonstra enorme desconhecimento em relação à realidade do uso de drogas no Brasil, para além de insistir em tese em momento nenhum demonstrada nos autos. O regime inicial deverá ser o aberto, com a conversão da pena corpórea em restritiva de direitos, na forma dos Arts. 33, 44 e 59 do Código Penal, além do recente habeas corpus coletivo de nº 596.603/SP, de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, deverá ser reconhecido ao requerente o direito de recorrer em liberdade." Finalmente, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. LUIZ FERNANDO MARCELINO SILVA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 29/33, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque dia 09 de outubro de 2020, por volta das 17h30min, durante estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual 64.879 de 20 de março de 2020), na Rua Doutor Jose Geraldo Velloce, nº 82, nesta cidade e comarca, foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo e transportando, para fins de tráfico, 13 (treze) comprimidos de METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA), com peso de 3,55g., sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 06). Tal substância causa dependência física e psíquica e consta da lista de substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98, conforme laudo de exame químico toxicológico de fls. 11/13. (fls. 40/42). Instruída com respectivo inquérito policial, a denúncia foi recebida (fls. 43/44), o réu foi citado (fls. 61) e apresentou resposta técnica (fls. 65/66). Não sendo hipótese de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 67) e, designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 1112), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, um pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou, em caso de condenação, fixação da pena base em seu mínimo legal, bem como a aplicação da benesse prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A presente ação penal deve ser acolhida. As provas trazidas aos autos demonstraram que o réu cometeu a infração penal que lhe foi imputada na denúncia. A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 06), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 11/13), bem como pela prova oral colhida na fase investigatória e ratificada sob o crivo do contraditório. A autoria, de igual modo, também é certa. Os policiais militares ouvidos na fase policial relataram que estavam em serviço no dia dos fatos, quando em patrulhamento por uma praça com constante frequência de traficantes, quando avistaram o acusado sozinho, o qual ao notar a aproximação da viatura levantou-se, pegou sua bicicleta e tentou sair dali, motivo pelo qual, mesmo não sendo conhecido foi abordado, e, em revista pessoal nele realizada, encontraram 13 comprimidos de uma droga sintética, a qual, segundo ele mesmo, seria ecstasy, a qual seria por ele comercializada numa festa que era realizada nas proximidades das Furnas, na área rural dessa cidade. Informaram que a droga foi apreendida e o acusado foi detido e apresentado no plantão policial. Esclareceram que é de conhecimento de ambos, como também da polícia em geral, que na região da estação das Furnas, na área rural de Araraquara, ocorrem festas com grande consumo de álcool e drogas. Disseram que naquele dia realmente ocorreu uma dessas festas, uma vez que houve várias ocorrências que foram atendidas durante a madrugada. (fls. 25 e 26). Ouvido em juízo, o policial militar Rodrigo Durante ratificou seu depoimento prestado na fase policial, acrescentando ainda que numa bolsinha que estava pendurada na bicicleta é que foram os 13 comprimidos de ecstasy. Confirmou que no momento em que foi abordado, o acusado confirmou que, a noite iria vender aquela droga para os

frequentadores de uma festa que ocorreria perto da estação de Furnas, festas estas chamadas de "Pancadões de Furnas". Disse que essa droga é mais cara, vendida para um público diferenciado, que normalmente é vendido cada comprimido entre R\$ 40,00 a R\$ 50,00. Disse ainda que cada comprimido tem a duração de cerca de 12 horas de duração. Afirmou que essa confissão informal do réu foi precedida da informação a ele a garantia de permanência em silêncio. Relatou ainda que o réu assinou e leu o que constava do boletim de ocorrência, do qual constou sua confissão informal de que a droga seria vendida mais tarde, na festa perto da estação de Furnas. Também ouvido em juízo, o policial militar José Luis Neiva, igualmente e de forma harmoniosa e coerente com seu colega de farda, confirmou seu depoimento prestado na fase investigatória, com os esclarecimentos acima prestados pelo policial Rodrigo Durante. Disse, assim como seu colega, que o réu achou interessante confessar a prática do crime para esclarecer que ele não iria vender a droga ali na praça, local conhecido como ponto de venda de drogas, mas sim a noite na festa. Larissa do Carmo da Cruz, testemunha arrolada pela defesa, disse em juízo que conhece o acusado há muito tempo, sabe é uma pessoa, honesto, trabalhador, de excelente família e desconhece qualquer fato que possa desabonar sua conduta. Interrogado na fase policial, o réu disse que, no dia dos fatos, no final da tarde, foi abordado por policiais militares quando transitava com sua bicicleta por uma via pública. Afirmou que foi submetido a uma revista pessoal e com ele foram encontrados 13 comprimidos de uma substância que não sabe do que se trata, conhecendo-a apenas por "bala". Confirmou que os comprimidos eram seus, que os adquiriu de um desconhecido, pelo valor de R\$ 10,00 cada um e iria consumi-los à noite, com a molecada, numa festa que seria realizada nas Furnas. Alegou que não é traficante e que não possui antecedentes criminais (fls. 29). Interrogado em juízo, o acusado alegou que passou todo o dia dos fatos na casa de sua ex, sendo que a noite iriam numa festa e adquiriu as "balas" para usa-las, quando então foi enquadrado pela polícia no poder delas. Disse que não pretendia vender a droga com ele apreendia. Afirmou que comprou a droga no bairro Yeda. Afirmou que depois dos fatos sua ex namorada faleceu num acidente de trânsito. Assim, as circunstâncias da abordagem, o relato dos policiais, aliados ao próprio teor do interrogatório do acusado na fase policial, não deixam dúvidas de que, no dia dos fatos, ele transportava drogas para fins de tráfico, ainda que se possa considerar que realmente pretendesse fazer uso de parte dela. Nesse sentido, o acusado, no dia dos fatos, no final da tarde, foi visto parado, sozinho, numa praça frequentada por traficantes, quando, ao avistar a viatura, tentou se evadir com sua bicicleta, mas foi abordado e com ele foram encontrados os 13 comprimidos de ecstasy. No momento de sua abordagem, o réu confirmou a propriedade da droga e que ela seria destinada à venda a consumidores que participariam de uma festa que ocorreria durante aquela noite, naquela região. Em seu interrogatório policial, o réu disse que iria consumir a drogas com a "molecada", o que é plausível com a afirmação de que iria vender a droga durante a festa. Os policiais confirmaram ainda que, ante as ocorrências que se seguiram que, na noite dos fatos, referida festa, que são comuns na região da estação das Furnas, realmente ocorreu. Além disso, o laudo pericial de fls. 11/13 confirma que a droga apreendida com o acusado tratava-se de 13 comprimidos particularizados da substância entorpecente denominada METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). Nota-se, portanto, que a prova produzida no inquérito é ratificada na instrução processual é conclusiva e indica, com segurança, a traficância. Vale deixar consignado, de início, que a prova oral colhida por meio dos depoimentos dos policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso ora em exame. Além disso, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime

de falso testemunho, diferente dos réus, que tem o direito de alegar o que lhes convier em sua defesa, uma vez que não são obrigados a produzir provas contra si mesmos. Neste sentido: PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas

versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (TJSP - Apel.185.484-3; d.j. 22.06.95). Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário (TJSP - Apel. 0082698-64.2010.8.26.0050; d.j. 11/04/13). No caso em questão, os depoimentos dos policiais são firmes e não há qualquer razão para suspeitar do que disseram, tampouco supor que pretenderam acusar o réu falsamente pela prática de crime tão grave, uma vez que até então sequer o conheciam. Com isso, inexistindo razão para se concluir que os policiais criaram alguma versão, inclusive de que encontraram drogas com o réu, claro que as declarações deles devem prevalecer. Não é crível que o réu a versão judicial do acusado no sentido de que todos aqueles 13 comprimidos seriam utilizados por ele na festa que ele participaria durante a noite. Se assim fosse, não estaria ele, no final da tarde, parado na praça, sozinho, com os 13 comprimidos individualizados da droga com ele apreendida e tivesse tentado empreender fuga de bicicleta assim que avistou a aproximação da viatura policial. É óbvio que ele ali se encontrava, sozinho, naquele local, próximo da região em que a festa se realizaria mais tarde, aguardando os consumidores da droga com ele apreendida para comercializá-la. Portanto, o depoimento dos policiais está em consonância com as circunstâncias nas quais as drogas foram apreendidas com o acusado, de modo que não há porque se colocar em dúvidas de que, no momento em que foi detido, ele confirmou que realmente os 13 comprimidos de entorpecentes seriam destinados à venda aos participantes da festa que se realizaria das proximidades em que ele se encontrava. Como já dito, mesmo que ele fosse ou tenha participado da festa, sua responsabilidade penal, ante as circunstâncias dos fatos, não fica afastada. Assim, as circunstâncias da abordagem do réu e da apreensão da substância entorpecentes são reveladoras e, considerando todos os elementos de prova já mencionados, inclusive as declarações do réu perante os policiais que fizeram sua detenção, convenço-me de que, ainda que seja ele usuário, no dia dos fatos ele praticava o tráfico de drogas, pois os comprimidos de entorpecentes com ele apreendidos realmente eram destinados à venda. Vale lembrara que, a condição de usuário não exclui a de traficante, conforme reiterada jurisprudência sobre o tema. Caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico e considerando preponderantemente o art. 42 da Lei de Drogas sobre o artigo 59 do Código Penal, observo o réu seja primário e não ostenta antecedentes criminais, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa uma vez que a pena base já foi fixada no mínimo legal. Está presente, todavia a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, consistente na prática do crime em ocasião de calamidade pública. Na lição de Cleber Masson, entende-se por calamidade pública "o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas" (in CÓDIGO PENAL COMENTADO, 7ª edição, Editora Método, página 396). Evidentemente, a pandemia de COVID-19 que aflige o mundo desde o fim do ano passado e o Brasil, especificamente, desde meados de março, é exemplo de calamidade pública. No Estado de São Paulo, o Decreto n.º 64.879, de 20 de março de 2020 reconheceu a existência desse estado. De qualquer forma, o período de calamidade pelo qual passa o Brasil constitui fato notório, porque atual. O fato notório independe de prova. Em tempos de pandemia, cidadãos de bem devem manter-se recolhidos em seus lares sempre que

possível, até mesmo para viabilizar o direcionamento prioritário de todos os recursos estatais para atendimento de ocorrências inevitavelmente ligadas à tragédia que assola o país. O réu, no entanto, optou por delinquir durante esse período. E isto revela especial insensibilidade moral, a justificar um apenamento mais severo. Por isso, elevo a pena anteriormente cominada em um sexto, a totalizar: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-dias-multa. No terceiro estágio, verifico que o acusado preenche os requisitos previstos no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que é ele primário e não há nada nos autos que indique ser ele integrante de organização criminosa ou traficante habitual, motivo pelo qual diminuo a pena em 2/3, totalizando, portanto, 1 ano, 11 meses e 10 dias e pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-dias-multa. Não obstante entendimento contrário desse juízo no sentido de que o tráfico de drogas não permite outro regime para início do cumprimento da pena a não ser o fechado, bem como de que em caso da prática do referido delito é insuscetível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento em sentido diverso, determinado, no caso de tráfico privilegiado, o regime inicial aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição acima aludida. Fixo, assim, o regime inicial ABERTO para início do cumprimento de pena. E, ainda, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, externando o entendimento consolidado nas Cortes Superiores de que o tráfico privilegiado não é equiparado a crime hediondo, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da sanção acima imposta, bem como prestação pecuniária no valor de 03 salários mínimos, a serem definidos na fase executória. Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal. Diante do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública contra LUIZ FERNANDO MARCELINO SILVA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 29/33, qualificado nos autos, e o CONDENO à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, iniciando-se o seu cumprimento no regime aberto, substituída na forma supra descrita, e ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e que não se mostram diferentes, nesse instante, a presença das circunstâncias que levariam a decretação de sua prisão preventiva, concedo-lhe o direito de, na mesma condição, recorrer da presente decisão. Decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em favor da União, na forma do art. 63 da Lei 11.343/06, por ausência de comprovação da origem lícita. Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, o acusado arcará com o pagamento de cem UFESP's a título de custas, observando se o caso os termos do artigo 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal), expedindo-se guia de execução, providenciando-se o necessário para a anotação da condenação no registro de antecedentes do réu. P.I.C." Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual (Teams/Microsoft), e a gravação estará diretamente disponível nos autos, ou em mídia CD/DVD. Saem cientes de que poderá ser fornecida cópia, quando solicitado, no prazo de 10 dias, sendo necessária para tanto, apresentação de mídia no ato do requerimento. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelos presentes neste ato a providência dos artigos 145, inciso III, e 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Nada mais. Para constar, eu, Sebastião José de Miranda Asturiano Filho, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz